

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים		
		עת"ם ???
משה איבגי, בעל חברת "המטמינים", ת.ז. ??? — ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ??? באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>העותר</u>
	-נגד-	
1. עיריית ירושלים — ועדת המכרזים של העירייה, באמצעות היועץ המשפטי לעירייה, מרחוב ??? 2. חברת "אקולו" (בבעלות מר יוסי כהן), מרחוב ??? באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>המשיבות</u>

מועד המצאת הבקשה: ???
מועד אחרון להגשת תגובה: ???

עתירה מינהלית

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1 שבה נבחרה המשיבה 2 כזוכה במכרז לפינוי הפסולת בתחומי המשיבה 1, ולהורות על עריכת מכרז חדש שבו לא ייטול חלק מנכ"ל המשיבה 1, מר יואב אסולין; כן מתבקש בית המשפט להורות למשיבות, כסעד זמני, להימנע מהתקשרות בחוזה מכוח המכרז ומכל פעולה לביצועו עד להכרעה בעתירה.

הרקע העובדתי

1. העותר הוא בעל חברת "המטמינים" (להלן: "המטמינים"), העוסקת בפינוי פסולת. המטמינים הגישו הצעה למכרז שפרסמה המשיבה 1 לפינוי פסולת בתחומה, בשווי של למעלה מעשרה מיליון ש"ח לשנה (להלן: "המכרז").

*** העתק הצעת המטמינים במכרז ואישור הגשתה מצ"ב כנספח 1.

2. המשיבה 2 היא חברה מתחרה לפינוי פסולת, בבעלותו של מר יוסי כהן (להלן: "מר כהן"), אשר אף היא הגישה הצעה למכרז.

3. כחודש לפני הגשת עתירה זו, בעת שהגיש את טפסי המכרז במשרדי המשיבה 1, נפגש מר כהן עם מר יואב אסולין (להלן: "המנכ"ל"), המשמש מנכ"ל המשיבה 1 וחבר ועדת המכרזים שלה. השניים הכירו זה את זה מתקופת שירותם הצבאי, שוחחו בלשכת המנכ"ל, ובמהלך אותה שיחה עדכן מר כהן את המנכ"ל כי הוא מתמודד באותה עת במכרז.

4. למחרת אותה פגישה נמצאה על שולחן המנכ"ל מעטפה, ובתוכה כרטיס טיסה לתאילנד ומכתב מאת מר כהן, שבו נמסר כי הזמין עבור שניהם כרטיסי טיסה ובתי מלון "דה לוקס" בתאילנד וכי ייפגשו בשדה התעופה בתוך שבועיים. הרי לנו טובת הנאה אישית בשווי כספי ניכר, שהוצעה לחבר ועדת המכרזים על ידי מציע במכרז, בעודו מציע.

5. יומיים לאחר מכן התכנסה ועדת המכרזים, שבה חבר המנכ"ל, ובהמלצתו נבחרה המשיבה 2 כזוכה במכרז. המנכ"ל לא גילה לחברי הוועדה את היכרותו עם מר כהן ואת טובת ההנאה שהוצעה לו, לא פסל את עצמו מלשבת בוועדה, ואף לא הסתפק בישיבה בה אלא המליץ בעצמו על בחירת המשיבה 2.

*** העתק הודעת המשיבה 1 בדבר תוצאות המכרז ובחירת המשיבה 2 מצ"ב **כנספח 2**.

6. העובדות בדבר הפגישה ובדבר המעטפה שנמצאה על שולחן המנכ"ל הובאו לידיעת העותר כשבועיים לאחר פרסום תוצאות המכרז, בהודעה שקיבל מאחד מעובדי לשכת המנכ"ל. מיד עם קבלת המידע פנה העותר לקבלת ייעוץ משפטי, ועתירה זו מוגשת בסמוך לכך.

*** העתק הודעת עובד לשכת מנכ"ל המשיבה 1 שנשלחה לעותר מצ"ב **כנספח 3**.

7. מועד כניסתו לתוקף של המכרז הוא בתוך שלושה חודשים ממועד ההחלטה. מכאן שהפעילות מכוחו טרם החלה, וכל שינוי במצב הדברים ניתן להיעשות עוד בטרם ייצרו המשיבות עובדות מוגמרות בשטח.

סמכות בית המשפט ומועד הגשת העתירה

8. בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה של רשות או גוף המנויים בתוספת הראשונה (מתוך חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000; להלן: "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים"), ובכללם ענייני מכרזים של רשות מקומית שענינם התקשרות בחוזה לרכישת שירותים (סעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים).

9. בענייננו ההחלטה המותקפת היא החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, שהיא רשות מקומית, בעניין התקשרות בחוזה לרכישת שירותי פינוי פסולת. משכך מצויה העתירה בגדר סמכותו של בית משפט נכבד זה, שבתחום שיפוטו פועלת המשיבה 1.

הטיעון המשפטי – הפרת חובתו של חבר ועדת המכרזים להימנע מניגוד עניינים

10. הלכה היא כי בעל תפקיד שקיים לגביו חשש לניגוד עניינים בעניין המובא לפני ועדה הפועלת מטעם הרשות חייב לפסול עצמו מלשבת באותה ועדה. בבג"ץ 11/11 ישראלי נ' שר החינוך (להלן: "עניין ישראלי") נפסק כי הסתרת היכרותו המוקדמת של השר עם המועמד מחברי הוועדה הקימה חשש ממשי לשיקולים זרים בבחירתו, ומשכך הורה בית המשפט על פסילת המינוי ועל קיום מכרז חדש שבו לא יוכל השר להשתתף.

11. בענייננו החשש לשיקולים זרים חמור לאין שיעור מזה שנדון בעניין ישראלי: המנכ"ל לא רק ידע כי מר כהן מתמודד במכרז, אלא קיבל ממנו – יומיים בלבד לפני התכנסות הוועדה – טובת הנאה אישית בשווי כספי ניכר, ולא גילה דבר מכל אלה לחברי הוועדה. משהמנכ"ל היה מצוי בניגוד עניינים מובהק, היה עליו לפסול את עצמו מלשבת בוועדה, ובוודאי שלא להמליץ על בחירת המשיבה 2. די בכך כדי להורות על ביטול ההחלטה.

12. אף הסעד המבוקש נגזר מעניין ישראלי: משנפל פגם של ניגוד עניינים בהליך הבחירה, אין די בהצהרה על הפגם, אלא יש לבטל את הבחירה ולהורות על עריכת מכרז חדש שבו לא ייטול המנכ"ל חלק. כך יובטח כי הזכייה תיקבע על יסוד שיקולים ענייניים בלבד, ותישמר אמון הציבור בטוהר הליכי המכרז של המשיבה 1.

אין בהלכה שנקבעה בעניין ברוך כדי לסייע למשיבות

13. בעת"ם 22/22 ברוך נ' עיריית רחובות (להלן: "עניין ברוך") נדחתה עתירה לפסילת מכרז, לאחר שנקבע כי היכרות מוקדמת בת שלוש שנה בין חבר הוועדה למציע אינה מעידה כשלעצמה על קשר פסול ואינה מקימה עילה לפסילת המכרז.

14. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין ברוך מהטעמים הבאים: ראשית, אין העתירה נסמכת על היכרות מוקדמת גרידא, אלא על טובת הנאה כספית ממשית שהעניק מציע לחבר ועדת המכרזים; שנית, סמיכות הזמנים מדברת בעד עצמה — המעטפה נמסרה יומיים בלבד לפני התכנסות הוועדה, ולאחר שמר כהן עדכן את המנכ"ל בדבר השתתפותו במכרז; שלישית, המנכ"ל לא הסתפק בישיבה בוועדה אלא יזם המלצה לבחירת המשיבה 2; רביעית, בשונה מעניין ברוך, ההיכרות וטובת ההנאה הוסתרו מחברי הוועדה — הסתרה שבעניין ישראלי נמצאה כמקימה חשש ממשי לשיקולים זרים. ואם לא די בכל אלה, בענייננו אין מדובר בקשר רדום מן העבר, אלא בקשר שחודש ואשר השניים תכננו להוסיף ולקיימו בתוך שבועיים — במסגרת נסיעה משותפת שמומנה בידי המציע הזוכה.

אין בעתירה שיהוי

15. בעת"ם 33/33 דני נ' קק"ל (להלן: "עניין דני") נדחתה עתירה מחמת שיהוי אף שהוגשה בתוך 45 הימים הקבועים בד"ן, זאת נוכח המשאבים הרבים שכבר השקיע הזוכה לקראת תחילת הפעילות ונוכח קביעה כי בבחינה אובייקטיבית עמד הזוכה בכל תנאי המכרז.

16. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין דני מהטעמים הבאים: ראשית, העתירה מוגשת כחודש בלבד לאחר החלטת הוועדה, ובתוך ימים ספורים מן המועד שבו נודעו לעותר העובדות המקימות את עילת העתירה; שנית, המכרז ייכנס לתוקף רק בתוך שלושה חודשים, וממילא לא נטען וממילא לא הוכח כי המשיבה 2 השקיעה משאבים כלשהם לקראת תחילת הפעילות, כך שאינטרס ההסתמכות שהוכר בעניין דני אינו מתקיים כאן; שלישית, הפגם שבו עסקינן אינו שיקול זר גרידא, אלא טובת הנאה אישית שקיבל חבר הוועדה מן המציע שעל בחירתו המליץ — פגם היורד לשורש תקינות ההליך, שאין בעמידה בתנאי המכרז כדי לרפאו. ואם לא די בכל אלה, דחיית העתירה מטעמי שיהוי בנסיבות אלה תיצור תמריץ להסתרת פגמים עד להיווצרות עובדות מוגמרות, ומשום כך אין להשלים עמה.

הסעד הזמני

17. מאחר שמועד כניסת המכרז לתוקף הוא בתוך שלושה חודשים, ומאחר שכל התקשרות או השקעה מכוחו עלולה ליצור את אותו אינטרס הסתמכות שבעניין דני שימש טעם לדחיית עתירה, מתבקש בית המשפט להורות למשיבות להימנע מהתקשרות בחוזה מכוח המכרז ומכל פעולה לביצועו עד להכרעה בעתירה. סעד זמני זה אינו כרוך בנזק למשיבות, שכן הפעילות מכוח המכרז טרם החלה.

לסיכום

18. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד: (א) לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1 שבה נבחרה המשיבה 2 כזוכה במכרז; (ב) להורות על עריכת מכרז חדש שבו לא ייטול חלק מנכ"ל המשיבה 1; (ג) להורות למשיבות, כסעד זמני, להימנע מהתקשרות בחוזה מכוח המכרז ומביצועו עד להכרעה בעתירה; (ד) לחייב את המשיבות בהוצאות העותר ובשכר טרחת עורך דין.

העתירה נתמכת בתצהירו של העותר, המצורף לה כדין.

_____ עו"ד ??? (מ"ר ???),

ב"כ העותר